

Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT

Nummer 7487 / 32

Betreft zaak: Zaaknr.:7487 / Herzieningsverzoek Hendriks

I Voorgeschiedenis

1. Op 19 oktober 2001 heeft de heer Hendriks, namens Stichting Vill'ABB, een klacht ingediend bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: NMa) tegen de gemeente Den Haag die de Mededingingswet zou overtreden. De afdeling Toezicht Kinderopvang van de GGD Den Haag (hierna: Tokin) en de gemeente Den Haag, maakten zich volgens de heer Hendriks schuldig aan ongelijke behandeling van Vill'ABB ten opzichte van de stichtingen Kinderopvang DAK, Centrale voor Kinderopvang Triodus en 2Samen (hierna gezamenlijk: de koepelorganisaties). Deze ongelijke behandeling betrof volgens de heer Hendriks onder meer de mate van dossiervorming en inspectie en de subsidieverstrekking. De klacht richtte zich tevens tegen de koepelorganisaties. Deze zouden begin 2001 actief dan wel passief hebben meegewerkt aan schriftelijke en mondelinge aansporingen van Tokin aan het adres van de cliënten van Stichting Vill'ABB om hun kinderen niet langer te laten opvangen door Stichting Vill'ABB, maar door de koepelorganisaties. Bij besluit van 14 december 2001 is de klacht van Stichting Vill'ABB door de directeur-generaal van de NMa (hierna: d-g NMa) afgewezen.¹
2. Op 27 december 2001 heeft de heer Hendriks, namens Stichting Vill'ABB, bezwaar ingediend tegen dit besluit. Bij besluit van 14 juni 2002 zijn de bezwaren van Stichting Vill'ABB door de d-g NMa ongegrond verklaard, aangezien niet gebleken was dat aan de in deze zaak aan de orde zijnde gedragingen van de koepelorganisaties een overeenkomst of afstemming ten grondslag lag.² De handelwijze van de koepelorganisaties viel derhalve niet onder het toepassingsbereik van de Mededingingswet. Tevens bepaalde de d-g NMa dat de gemeente Den Haag niet als onderneming in de zin van de Mededingingswet handelde, maar in haar hoedanigheid van overheidsorgaan. De gedragingen van de gemeente Den Haag vielen derhalve buiten de reikwijdte van de Mededingingswet. Stichting Vill'ABB heeft geen beroep ingesteld

¹ Kenmerk 2745/16

² Kenmerk 6854/67

tegen het besluit op bezwaar van 14 juni 2002, waardoor dit besluit formele rechtskracht heeft gekregen.

3. Bij brief van 13 november 2009 heeft de heer Hendriks namens de organisaties 1) Stichting Stedebouw & Stadsherstel, 2) Stichting Vill'ABB, 3) Familia Maxima B.V. en 4) Stichting 't Hollandsch Huys de Raad van Bestuur (hierna: Raad) van de NMa verzocht het besluit van de d-g NMa van 14 december 2001 te herzien. Dit verzoek is bij besluit van 12 maart 2010 afgewezen met als reden het ontbreken van *nova* in de zin van artikel 4:6 Awb.³
4. Tegen dit besluit heeft de heer Hendriks, namens de vereniging Familia Maxima, bezwaar aangetekend bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit met het verzoek om, met toepassing van artikel 7:1a, eerste lid, Awb, in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de rechtbank. Dit verzoek is gehonoreerd en het bezwaarschrift is doorgezonden naar Rechtbank Rotterdam, afdeling bestuursrecht. In haar uitspraak van 9 december 2010 heeft de Rechtbank het beroep ongegrond verklaard.⁴ De rechtbank heeft geoordeeld dat de indiener van het beroep bij het herzieningsverzoek geen nieuwe feiten of veranderende omstandigheden naar voren heeft gebracht die NMa had moeten nopen tot herziening van zijn verzoek.
5. Tegen deze uitspraak is de heer Hendriks, namens 1) Vereniging Familia Maxima, 2) Stichting Stedebouw & Stadsherstel, 3) Stichting Vill'ABB, 4) Familia Maxima B.V., en 5) Stichting 't Hollandsch Huys in beroep gegaan bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB). Het College heeft in haar uitspraak van 14 maart 2012 de appellanten 2 t/m 5 niet ontvankelijk verklaard. Daarnaast heeft zij de aangevallen uitspraak van Rechtbank Rotterdam bevestigd.⁵

II. Het verzoek van 5 juni 2012

6. Op 5 juni 2012 heeft de heer Hendriks, namens Stichting 't Hollandsch Huys, de NMa verzocht alsnog onderzoek te doen naar het vermeende kartel in de Haagse kinderopvang. Ter ondersteuning van dit verzoek heeft de heer Hendriks ten eerste aangevoerd dat hij signalen heeft waaruit kon worden opgemaakt dat de gemeente den Haag accommodaties aanbiedt aan drie kinderopvangorganisaties tegen niet-marktconforme voorwaarden. Tevens zouden er in de sfeer van planologische voorbereidingen voordelen genoten zijn door deze drie partijen.

³ Kenmerk 6854/23

⁴ LJN: BV6072

⁵ LJN: BV9534

7. Ten tweede heeft de heer Hendriks bij een nadere aanvulling van zijn verzoek van 5 juni 2012 aangevoerd dat de intrekking door de gemeente Den Haag van de houdersvergunning van Vill'ABB voor de exploitatie van een kinderdagverblijf aan de Stationsweg 170 in een ander licht moet worden gezien, omdat gegevens boven water zijn gekomen over de plannen van de Gemeente Den Haag om het pand beschikbaar te krijgen als horeca pand, in het kader van de ontwikkeling van het gebied tot horecagebied.
8. Tenslotte heeft de heer Hendriks in een nadere aanvulling van zijn verzoek aandacht gevraagd voor de vraag waarom de NMa eerder door hem ingebrachte stukken niet heeft betrokken in het rapport "Marktwerving in de kinderopvang" van 8 oktober 2009. Dit rapport heeft de NMa destijds in opdracht van het Ministerie van OC&W laten uitvoeren door Regioplan.

III Beoordeling

Herhaalde aanvraag

9. De NMa heeft de heer Hendriks bij brief van 30 juli 2012 laten weten het verzoek van Stichting 't Hollandsch Huys te beschouwen als een herhaalde aanvraag in de zin van artikel 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). De heer Hendriks bestrijdt dat er sprake is van een herhaalde aanvraag. Als reden daarvoor voert hij aan dat (i) Stichting 't Hollandsch Huys pas is opgericht na de eerste klacht in 2001, die de heer Hendriks namens Vill'ABB deed; (ii) Stichting 't Hollandsch Huys niet is opgericht, en in eerste aanleg ook niet werd niet bestuurd door de heer Hendriks. Na oprichting werd de stichting bestuurd door twee eigenaren van Catalpa.
10. De Raad van Bestuur van de NMa (hierna: de Raad) overweegt dat (i) de besluitaanvraag van 19 oktober 2001, (ii) de besluitaanvraag van 13 november 2009 en (iii) de besluitaanvraag van 5 juni 2012 alle drie zijn gedaan door de heer Hendriks. In al deze gevallen handelde hij namens een rechtspersoon waarvan hij op dat moment bevoegd bestuurder was.⁶ Het enkele feit dat de aanvraag van 2001 namens een andere rechtspersoon is gedaan dan de aanvraag in 2012 doet niet af aan het feit dat de aanvrager dezelfde is. De Raad concludeert dan ook dat het hier dezelfde aanvrager als in 2009 betreft. Bovendien strekt de aanvraag tot het in het leven roepen van hetzelfde rechtsgevolg, te weten een overtreding van artikel 6 van de Mededingingswet door de gemeente Den Haag en de koepelorganisaties.

⁶ Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat de heer Hendriks sinds 10 mei 2002 voorzitter is van Stichting 't Hollandsch Huys. Deze stichting was zowel in 2009 als in 2012 (een van de) aanvrager(s) van een besluit.

11. Ambtshalve heeft de NMa naar aanleiding van de inwerkingtreding van de wet Markt en Overheid op 1 juli 2012 getoetst of onderzoek naar de door de heer Hendriks gesignaleerde gedragingen zou kunnen leiden tot de vaststelling van een overtreding van artikel 25i van de Mededingingswet. Daargelaten de vraag of de signalen hiertoe voldoende aanknopingspunten bieden, overweegt de Raad dat deze signalen betrekking hebben op activiteiten die ook vóór de inwerkingtreding van de Wet Markt en Overheid werden verricht. Aangezien artikel 25i tot 1 juli 2014 niet van toepassing is op activiteiten die ook vóór de inwerkingtreding van de wet Markt en Overheid werden verricht is de Raad van oordeel dat deze signalen op dit moment niet kunnen leiden tot de vaststelling van een overtreding van artikel 25i van de Mededingingswet.
12. De Raad is daarom van oordeel dat de aanvraag van stichting 't Hollandsch Huys een herhaalde aanvraag in de zin van Art. 4.6 Awb is.

Beoordeling nova

13. Bij een herhaalde aanvraag is de aanvrager gehouden nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden (*nova*) te vermelden. Deze *nova* moeten van zodanige aard zijn dat zij tot een andere beschikking aanleiding kunnen geven. Het bestuursorgaan heeft in deze een ruime beoordelingsmarge.⁷ Zijn *nova* niet gebleken, dan kan het bestuursorgaan op grond van artikel 4:6, tweede lid, Awb de aanvraag afwijzen onder verwijzing naar zijn eerdere besluit. Aangezien de Raad naar aanleiding van het door de heer Hendriks namens 1) Stichting Stedebouw & Stadsherstel, 2) Stichting Vill'ABB, 3) Familia Maxima B.V. en 4) Stichting 't Hollandsch Huys ingediende herzieningsverzoek op 12 maart 2010 een afwijzend besluit heeft genomen, wordt hierna beoordeeld of thans aanleiding bestaat dit besluit te herzien.
14. De heer Hendriks heeft ter onderbouwing van zijn aanvraag van 5 juni 2012 onder meer de volgende informatie overgelegd⁸: ten aanzien van het tegen niet-marktconforme voorwaarden aanbieden van kinderopvanglocaties en het bieden van andere voordelen aan de koepelorganisaties heeft de heer Hendriks een brief overgelegd van een persoon die de NMa hierover nader wilde informeren en een brief van een persoon die nadere informatie had over de verbouwingskosten van een door de gemeente verhuurd pand aan één van de koepelorganisaties. Ten aanzien van de intrekking van een houdersvergunning -met als reden het in dienst hebben van te weinig gediplomeerde groepsleidsters- heeft de heer Hendriks een brief overgelegd van het Centrum

⁷ Vergelijk CBB 4 juli 2001, LJN: AB3011.

⁸ Zie dossierstukken 7487/4 t/m 7487/26 en 7487/29 t/m 7487/31.

Arbeidsverhoudingen uit november 2002 waaruit zou blijken dat medewerkers die door GGD/Tokin niet bevoegd werden geacht dat wel waren. Tenslotte heeft de heer Hendriks een aantal mediaberichten toegestuurd aan de NMa.

15. Naar het oordeel van de Raad bevat de door de heer Hendriks aangedragen informatie geen *nova* in de zin van artikel 4:6 Awb. De informatie bevat geen nieuwe indicaties dat de koepelorganisaties een kartel vorm(d)en of dat hun gedragingen aan te merken zijn als een overeenkomst of onderling afgestemde feitelijke gedraging in de zin van artikel 6, eerste lid, van de Mededingingswet. Evenmin blijkt uit de ingediende stukken dat de gemeente Den Haag optreedt dan wel heeft opgetreden als kartelondersteuner. Daarnaast doet een aanzienlijk deel van de aangedragen informatie – zoals de toegestuurde mediaberichten – niet ter zake en wordt geen ander licht op de onderhavige zaak geworpen.
16. Voor zover de aangedragen informatie betrekking heeft op het niet betrekken van de door de heer Hendriks eerder ingebrachte informatie in het rapport “Marktwerving in de kinderopvang” uit 2009, merkt de Raad op dat dit rapport een algemeen karakter had en niet ten doel had een specifieke situatie in Den Haag te onderzoeken. Ook deze door de heer Hendriks aangedragen informatie doet niet ter zake en werpt geen ander licht op de zaak.

Besluit

De Raad wijst het verzoek d.d. 5 juni 2012 om herziening van het besluit van 12 maart 2010 op het herzieningsverzoek van 13 november 2009, met kenmerk 6854/23, af.

Datum: 19 november 2012

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,
namens deze:

w.g. Chris Fonteijs
Voorzitter van de Raad van Bestuur

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Juridische Dienst, Postbus 16326, 2500 BH, Den Haag. In dit bezwaarschrift kan een belanghebbende op grond van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht de Raad van Bestuur verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter.